

0007663-45.2017.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... do denunciado pela prática do delito de Tráfico de Drogas e Condutas Afins.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007663-45.2017.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007663-45.2017.8.26.0635

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7192/2017 -

10º Distrito Policial - Penha, 1116/2017 - 10º Distrito Policial - Penha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE SILVA DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

ALEXANDRE SILVA DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 01 de setembro de 2017, por volta das 21h40, na Rua Londrina, nº 261, esquina com a Rua Londres, Cangaíba, nesta cidade e Comarca da Capital, guardava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 3,4 g (três gramas e quatro decigramas) de Tetrahydrocannabinol e 17,9 g (dezessete gramas e nove decigramas) de Cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e laudo de constatação de fls. 22/24, sem autorização e em desacordo com determinação legal e Regulamentar.

Segundo a exordial, Policiais Militares receberam denúncia no sentido de movimentação suspeita relacionada ao tráfico de drogas no local, bem como que a pessoa conhecida como "Bozó" estaria envolvida. No local acima mencionado, os policiais militares encontraram com o denunciado e outras duas pessoas. O denunciado trazia consigo e guardava no interior de uma pochete as drogas apreendidas (fls. 18/19), bem como a quantia em dinheiro equivalente a R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Com a chegada dos policiais, o denunciado imediatamente

jogou a pochete contendo a drogas apreendidas embaixo de veículo ali estacionado, bem como se recusou a ir até os policiais.

No interior da pochete foram encontrados 10 (dez) invólucros plásticos de cor roxa e 16 (dezesseis) invólucros plásticos transparentes, ambos contendo em seu interior cocaína, além de 03 (três) porções da substância conhecida como maconha (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 18/19). Em seu interrogatório de fls. 10, Alexandre alega ser também conhecido como "Bozó". A denúncia anterior no sentido do tráfico de drogas no local bem como seu responsável, "Bozó", apelido do denunciado, a quantidade de drogas apreendida, a diversidade de drogas apreendida, a forma de acondicionamento da droga, a quantia em dinheiro encontrada na posse do denunciado, bem como as demais circunstâncias do flagrante, tornam evidente que a droga apreendida destinava-se a mercancia ilícita.

Na denúncia foram arroladas as testemunhas Joice Rangel dos Santos, Mauricio Mori Lima Enjoji e Wilmo dos Santos Ferreira.

Recebida a denúncia em 03/10/2017 às fls. 115/116.

O réu foi citado por carta não voltou (fls. 163/164).

Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública a fls. 168. Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia, foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 170/171).

Laudo pericial da bolsa juntado a fls. 136/137.

Laudo pericial dos entorpecentes juntado a fls. 22/24 e 262/264.

Laudo pericial do telefone celular juntado a fls. 265/267.

Em audiência realizada no dia 06/07/2022, foram ouvidas as testemunhas Joice e Maurício (278/279). A defesa insistiu na oitiva de Wilmo dos Santos Ferreira e posteriormente desistiu dela em razão da não localização de outros endereços da testemunha (fls. 283).

Foi designada audiência em continuação, para interrogatório do réu (fls. 286).

Certidões criminais do acusado juntada a fls. 246/248, sendo o réu reincidente com maus antecedentes.

Em audiência o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação penal, no mesmo sentido o pedido da defesa.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Tráfico de Drogas e Condutas Afins.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição/apreensão/avaliação (fls. 18/19), termo de declarações e interrogatório (fls. 06/11), laudo pericial (fls. 22/24, 136/137, 262/264 e 265/267) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

O mesmo não é possível dizer da autoria.

Na delegacia, o réu Alexandre Silva da Costa disse que reside na Rua Londrina, 261, onde funcionava anteriormente a oficina de seu sogro, Wilmo e atualmente está desativada, sendo que ele aluga como estacionamento de veículos. Na data de hoje encontrava-se no local quando chegaram policiais militares, os quais disseram terem recebido denúncia versando sobre tráfico de entorpecentes, sendo atendidos pelo seu cunhado Bruno e seu sogro, pediram para entrar. O interrogado estava no quintal na companhia de Eduardo e vulgo "Boiadeiro", sendo que os policiais pediram para se levantarem e virem na direção do portão, o que os três acataram, foram revistados e nenhum objeto foi encontrado. Os policiais entraram e vistoriaram o quintal,

perguntando ainda quem seria o "Bozó", tendo respondido que era sua pessoa, quando então a policial feminina pediu que a acompanhasse até sua casa, nos fundos do imóvel. A casa foi revistada, nada encontraram e nesse interim continuaram a fazer revista no quintal, sendo que a policial feminina veio com uma pochete na mão, dizendo que tinha achado droga e que ia achar mais, tendo ainda dito a ela, que achou mas tinha muita gente no quintal e muita gente circula no local, dia e noite. Quando ao dinheiro no valor de duzentos e oitenta reais, este encontrava-se dentro de seu bolso. Declara que não encontrava-se em poder de nenhuma pochete contendo entorpecentes e não jogou essa pochete debaixo de nenhum veículo ali estacionado, sendo que esses entorpecentes foram encontrados cerca de vinte minutos depois dos policiais já terem abordados todos os presentes ao local. Esclarece ainda que quando a policial exibiu as drogas encontradas a sua pessoa, estava presente seu sogro e um outro policial, sendo que o que lhe foi exibido eram dez pinos de cocaína. Declara ainda que as três porções de maconha, a polícia teria encontrado em poder de um dos dois indivíduos que tinham também sido abordados, não se lembra qual deles.

Em juízo, o réu Alexandre Silva da Costa disse que tinha chegado há 40 minutos, e estavam com amigos tomando cerveja, quando viu duas viaturas passando por 3 vez. Na rua onde residia é ponto de venda de drogas. Cerca de meia hora depois, os policiais pararam, bateram no portão, alguém atendeu, perguntaram se estava tudo bem porque tinham feito denúncia de briga de casal, eles entraram, abordaram, os colocaram para fora, não encontraram nada, depois fizeram varredura no local, também não encontraram nada. Chamaram outras viaturas, entraram novamente e saíram com uma pochete dizendo que era do depoente.

No caso em tela além de não haver prova quanto a autoria, é de se verificar a ilegalidade na violação do seu domicílio.

A testemunha Joice Rangel dos Santos (policial militar) disse que foram acionados via COPOM para averiguação de suspeito que pelo local dos fatos havia comercialização de drogas. Foram ao local, foi feito contato com o responsável do local que autorizou a entrada, as pessoas foram abordadas. O local é uma funilaria e um deles dispensou uma pochete. Toda a entrada foi autorizada pelo proprietário do local. Tinha cerca de 3 ou 4 pessoas no local. É um espaço grande e no fundo é uma residência e a parte da frente é utilizada para reforma de veículo. Seu parceiro que viu a pessoa dispensando. Não seu para ver exatamente o que eles estavam fazendo. Já tinham tido outras denúncias. O local é um portão, com um espaço que da pra abrir, quando encostaram o carro o proprietário abriu o portão e seu parceiro que viu o réu dispensando. O proprietário falou que lá entram várias pessoas. Não se recorda das drogas. Acha que tinha dinheiro na pochete. Não se recorda do apelido do réu.

A testemunha Mauricio Mori Lima Enjoji (policial militar) afirmou que foi paga ocorrência via COPOM sobre tráfico de entorpecente. Chegando ao local, na residência tinham alguns carros de sucata, o proprietário franqueou a entrada e tinham mais 3 indivíduos sentados próximos de um carro, pediu para que eles se levantassem, e um deles jogou uma pochete, foi feita a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado além de dinheiro e onde eles estavam, viram a pochete com entorpecente. Tinha no local o proprietário, a filha e onde estava o réu estavam mais duas pessoas. Pode ver que o réu quem largou a pochete. Não lembra o que as pessoas estavam fazendo. Não lembra se o réu tinha apelido nem se a denúncia falava sobre apelido. Não lembra se o réu resistiu a ordem de chamada. Não se recorda do réu na presente data. Não lembra se o portão era vazado ou fechado. Quem estava do lado de dentro não podia ver quem estava se aproximando. Estavam fardados, falaram com o proprietário, e depois que franqueou a entrada que viram as demais pessoas. Tinha carros em estado de sucata. A pochete foi encontrada embaixo de um carro, acha que o réu estava perto do carro. Quando entraram viram o pessoal próximo a um carro. Não se recorda bem devido o tempo passado. Estava escuro pela hora. Não sabe a distância que estava do carro.

Pelo relato dos policiais, não é possível saber de fato se o réu quem estaria com o entorpecente, já que tinham várias pessoas no local e os seus relatos pareceram demasiadamente confuso não ficando clara como se deu a operação.

As demais pessoas que estavam no local não confirmaram a versão dos policiais, pelo contrário Wilmo, ouvido em sede inquisitória negou que o réu estivesse traficando no local.

Os milicianos ainda não se recordaram de detalhes importantes da investigação como por exemplo o fato do réu ter supostamente um apelido que haveria denuncia contra ele.

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: “A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente”. (TJSP – AC 142.227-3 – Rel. Nelson Fonseca – JTJ 170/315).

Se não bastasse isso, a teor do art. 5º, XI, da CF/88, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Da interpretação do referido dispositivo constitucional decorre que o ingresso no domicílio do réu seria admitido em três situações, conforme será esclarecido com maior profundidade adiante:

I) Se houvesse autorização judicial para tanto.

II) Se houvesse consentimento válido e inequívoco do morador.

III) Se houvesse fundadas razões concretas da ocorrência de flagrante delito no local e a urgência não permitisse a espera por mandado judicial.

Com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos em contrário, entendo que nenhuma delas estava presente no caso em tela.

Vejamos.

I) AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

A ausência de autorização judicial para tanto é incontroversa.

II) CONSENTIMENTO DO MORADOR

O tema do consentimento do morador é ainda incipiente na doutrina e na jurisprudência pátrias, especialmente em razão da falta de especificação legal dos requisitos de sua validade, diferentemente do que ocorre em outros países, nos quais, além de haver regulamentação legal mais concreta, a doutrina e a jurisprudência já se debruçam sobre o tema há tempos. Cito como exemplo Espanha, Portugal, França e Estados Unidos.

Um dos poucos a escrever a respeito no Brasil, Pierpaolo Cruz Bottini, em artigo publicado no site Conjur<https://www.conjur.com.br/2014-nov-11/direito-defesa-buscas-policiais-mandado-parecem-normatizado>, assim discorre:

“Como pontua a doutrina processual penal, durante o dia ou à noite, o morador pode permitir a entrada em sua casa e, nessa situação, dispensa-se mandado judicial para realização de busca domiciliar. O consentimento, porém, deve ser real e livre, desprovido de vícios como o erro, violência ou intimidação.

Evidentemente que, em cada caso concreto, o consentimento do morador deve ser analisado com cautela e nunca presumido, especialmente para que se evitem abusos da autoridade policial. Sobre o cenário de muitos casos brasileiros, Cleunice Pitombo destaca: “Infelizmente, no Brasil e em outros lugares, em que o miúdo desconhece os próprios direitos, o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador, temeroso, tímido, não lhe coarctar o passo”.

O TJ-RS recentemente destacou a invalidade do consentimento de pessoa investigada por tráfico de drogas. Na ocasião, o desembargador relator pontuou: “Não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir da permissão informal do proprietário. Do consentimento a que se refere o artigo 5º, XI, da Constituição Federal não se infere que poderão ser realizadas buscas sem determinação judicial, apenas sob a anuência do morador. Se assim fosse, veríamos-nos diante de um quadro temerário, no qual os mandados de busca e apreensão seriam dispensáveis, já que

polícia sempre poderia conseguir, extrajudicialmente, o 'consentimento' do proprietário. Afinal, é de se ter em conta que, nas circunstâncias descritas nos autos esse aval foi dado sob constrangimento" (Ap 70058172628, relator desembargador Diógenes V. Hassan Ribeiro, 3ª Câmara Criminal, DJ 24.06.2014). Destarte, se há o consentimento do morador para buscas domiciliares, algumas questões devem ser bem refletidas: (i) forma do consentimento; (ii) pessoa que consente e seu grau de esclarecimento sobre as implicações da medida.

Sobre a forma do consentimento, deve ser expresso e jamais presumido, sendo que não há previsão legal de forma especial. Relevante destacar doutrina portuguesa que pontua a necessidade de documentação do consentimento, por qualquer forma, mesmo gravada: "Relativamente à forma do consentimento, parece-nos resultar da lei que o mesmo não pode ser dado de forma tácita, nem por via de presunção. A exigência de consentimento expresso pode retirar-se da circunstância de a lei impor obrigatoriamente a documentação do mesmo. (...). Já no que respeita à forma de documentação do consentimento, o Acórdão da Relação de Lisboa de 13 de Janeiro de 2000 veio pronunciar-se no sentido de que a lei processual penal não exige forma especial (pode ser verbal), bastando que o mesmo seja prestado anteriormente à busca e fique, de qualquer forma, documentado. A documentação do consentimento verbal pode ser efetuada, por exemplo, através de gravação sonora".([5])

No tocante à pessoa que consente, deve ser aquele titular do direito à inviolabilidade do domicílio. A doutrina destaca que a permissão deve ser do próprio sujeito da medida de busca e apreensão ou de outra pessoa que possa, legitimamente, representá-lo. Ressalvas são feitas, ainda, às habitações coletivas, em que o consentimento por um dos moradores não autoriza a busca na casa ou aposento de terceiros.([6])

No entanto, maior relevo tem a questão do grau de esclarecimento do morador que consentiu na realização da busca e apreensão. Para que se solucione o conflito de interesses – busca da verdade para realização da justiça e inviolabilidade do domicílio – por via consensual, é necessário que aquele que consente tenha pleno conhecimento das circunstâncias e consequências da realização da busca domiciliar, bem como que isso seja documentado.

No ponto, não há previsão legal. Contudo, tratando-se de medida que pode implicar a produção de prova contra o próprio morador que consente com a busca, para que ele decida de forma justa e válida se franqueará a entrada em sua residência, necessário que no mínimo lhe sejam esclarecidos seus direitos e o alcance da inviolabilidade do domicílio, bem como as consequências da realização da busca domiciliar. A mesma lógica e o mesmo cuidado são observados nos procedimentos de interrogatórios, tanto judicial quanto policial, a fim de garantir o direito da pessoa de não produzir prova contra si (deriva das previsões constitucionais – artigo 5º, LVII e LXII – e consagrado do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º).

Nesse aspecto, surpreendem a doutrina e a jurisprudência espanhola, já sensibilizadas com a questão, ao sustentarem que o consentimento deve ser prestado em circunstâncias que garantam uma decisão consciente e ponderada pelo morador. Defendem, em resumo: "a) que o consentimento deve produzir-se em condições de serenidade e liberdade ambiental necessárias para autorizar a invasão de um direito fundamental como a inviolabilidade de domicílio; b) que, atendendo ao caráter fundamental do direito tutelado, a diligência se inicie com a informação do visado sobre o alcance do direito à inviolabilidade do domicílio e de seus limites, e com uma pergunta clara e concisa sobre se o visado tolera ou não a intromissão; c) a presença de um 'letrado', para garantir a autenticidade da manifestação de vontade, evitando perguntas capciosas ou sugestivas, bem como qualquer forma de coação ou ameaça; d) que entre a solicitação do consentimento e a resposta, por parte do visado, medie um pedido de tempo suficiente para este meditar com calma sobre o assunto e compreenda o significado e alcance da sua resposta".

(...)

Conclui-se que a autorização para a violação do domicílio, nos casos de flagrante delito, depende de um estado de flagrância claro, constatado antes da invasão do domicílio e passível de demonstração posterior. As suspeitas, fundadas em relatos

declarados ou ocultos, devem ser submetidas a prévia autorização judicial, mediante representação.

Além disso, no ponto do consentimento, necessária observância de cuidados, a fim de assegurar que este seja consciente e válido. Frise-se que o consentimento não se presume e requer prova, cujo ônus é do Estado (TRF-2 Região, RSE 200551015058355, DJ 22.10.2008). Mais do que isso, parece-nos essencial que sejam esclarecidos, ao sujeito da medida e de forma documentada, os seus direitos, o alcance da inviolabilidade do domicílio e as consequências de sua decisão por franquear a entrada de policiais para a busca domiciliar. Trata-se de medidas mínimas para coibir abusos da autoridade policial e fazer valer um Estado Democrático de Direito." (grifo não original).

Na jurisprudência dos tribunais superiores, o tema até pouco tempo atrás não vinha sendo enfrentado, salvo lateralmente em alguns casos.

O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal levantou o problema em seu voto condutor no RE n. 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral), mas não o enfrentou a fundo por não ser o cerne do tema em julgamento:

"Outra questão não apreciada é a validade do consentimento do morador. As hipóteses concretas podem revelar desdobramentos complexos, seja quanto à prova do consentimento, seja quanto a sua validade e suficiência. A Suprema Corte dos Estados Unidos vê com desconfiança o consentimento do morador obtido pelo agente estatal "sob autoridade governamental" (under government authority) ou "sob as cores do uniforme" (under color of office) - respectivamente, casos *Amos v. United States*, 255 U.S. 313 (1921) e caso *Johnson v. United States* 333 U.S. 10 (1948). Já houve algum debate sobre o assunto no HC 79.512, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 16.12.1999. O tema em julgamento, no entanto, não se presta a resolver a questão" (RE n. 603.616, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe-093).

No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, o tema também já foi trazido de passagem em alguns julgados:

"Por fim, merece destaque a afirmação constante dos autos de que, ao se dirigirem para a residência, os policiais tiveram a entrada franqueada pela proprietária do imóvel (fls. 3 e 256). Tal realidade, a meu ver, demonstra muito mais uma situação aguda, uma vontade externada sob domínio de intensa pressão, do que uma pouco crível colaboração para que, voluntariamente, fosse autorizado o ingresso de agentes policiais em sua residência para a busca domiciliar. Em relação ao cenário brasileiro, Cleunice Pitombo, na mesma linha, destaca: "Infelizmente, no Brasil e em outros lugares, em que o miúdo desconhece os próprios direitos, o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador, temeroso, tímido, não lhe coarcta o passo" (Da busca e apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 133-134)." (trecho do voto do Ministro Rogério Schietti por ocasião do julgamento do RESP Nº 1.690.854 - RJ)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CF). ATUAÇÃO DE POLICIAIS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE DA PROVA. ENTRADA NO DOMICÍLIO FRANQUEADA PELA TIA DO PACIENTE, DIANTE DA ADVERTÊNCIA DE MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO. INDIFERENÇA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. (...) 4. No caso, embora a tia do paciente tenha franqueado a entrada dos policiais no imóvel da família, diante da advertência de monitoramento estatal prévio, a "autorização" não torna lícito o procedimento policial que, diante de denúncia anônima, não procedeu investigação preliminar para confirmar, ou não, os elementos de suspeita de autoria e de materialidade delitiva. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar a nulidade da prova, restabelecendo a sentença absolutória.

(...) No ponto, registro que a denúncia anônima não foi minimamente esclarecida nos autos pelos agentes públicos policiais e a suposta autorização para ingresso no imóvel, embora confirmada pela tia do réu, não é válida, tampouco concede licitude à ação policial, pois se trata de pessoa com desconhecimento da lei, desassistida de profissional da área jurídica, hipossuficiente frente ao aparato policial (DENARC) que, por si só, exerce coação com a mera presença e, portanto,

compreensível que a tia do réu tenha lhes autorizado a entrada no imóvel sem o conhecimento acerca da inviolabilidade do domicílio que lhe assiste na condição de residente. (STJ - HC: 423653 RS 2017/0288292-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)

No julgamento do REsp 1.558.004-RS, em 22.08.2017, o Ministro Rogério Schietti avançou um pouco mais sobre a questão dos requisitos de validade do consentimento citando o entendimento do Tribunal Supremo Espanhol a respeito:

"Sobre o específico tema do consentimento do interessado, o Tribunal Supremo espanhol decidiu, por mais de uma vez (SSTS. 1803/2002, 261/2006 e 951/2007), sobre a necessidade do preenchimento de requisitos para que a manifestação da vontade seja considerada válida, desprovida de pressão psicológica que a impeça de exercer seus direitos constitucionais, notadamente o previsto no art. 18.2 da Constituição da Espanha. Esse consentimento, "verdadera fuente de legitimación del acto de injerencia de los poderes públicos en el domicilio del imputado", decorre do próprio enunciado constitucional, como também do art. 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do art. 8 da Convenção de Roma e do art. 17 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Segundo a Corte espanhola, são os seguintes os requisitos a serem considerados para analisar o consentimento autorizado de ingresso no domicílio:

a) Outorga por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos;
b) Outorga consciente e livre, a qual requer: b1) que não esteja invalidada por erro, violência ou intimidação de qualquer modo; b2) que não seja condicionada a alguma circunstância periférica, como promessas de qualquer atuação policial; b3) que se o consentimento for de pessoa que estiver presa/conduzida, não pode validamente prestar o consentimento se não tiver antes a assistência de um defensor, do que constará da diligência policial (STS 2-12-1998). Isso porque se a assistência de defensor é necessária para que o conduzido preste declarações, dado o prejuízo aos seus direitos, o consentimento também o será, dada a "intimidação ambiental" ou "a coação que a presença dos agentes da atividade representa" (STS. 831/2000); c) Pode ser prestada oral ou por escrito, porém sempre vertida documentalmente; d) Deve ser outorgada expressamente, não servindo o silêncio como consentimento tácito, em face do princípio in dubio pro liberdade (SS. 7.3 y 18.12.97 e S. 23.1.98). Sobre este item, refere o Tribunal Supremo que, embora autorizado o consentimento presumido pelo art. 551 do CPP espanhol, esse dispositivo "ha de interpretarse restrictivamente, pues el consentimiento tácito ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios tanto de no oposición cuanto, y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presunto hay que resolverla en favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el Tribunal Constitucional de interpretar siempre las normas en el sentido mas favorable a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada" (STS 4761/2013); e) Deve ser outorgado pelo titular do domicílio. A relação jurídica entre o titular do direito e sua salvaguarda deve prevalecer, não sendo necessária a propriedade. Em caso de várias pessoas terem seu domicílio no mesmo lugar, não é necessário o consentimento de todos, bastando a anuência de um dos cotitulares, desde que não tenha interesses contrapostos (STS. 779/2006); f) O consentimento deve ser outorgado para um caso concreto, sem que seja usado para fins distintos, ou seja, vigora a especialidade da busca (STS, sentença de 6 de junho de 2001); g) São dispensadas as formalidades exigidas no art. 569 da Ley de Enjuiciamiento Criminal (CPP da Espanha).

Esses requisitos, evidentemente, não têm sido nem sequer ventilados pela jurisprudência pátria, muito menos por leis de nosso país ou, ainda, por regramentos administrativos, mas refletem uma orientação que poderia ser adotada, na medida do possível, com vistas a minimizar a praxe, tão comum em comunidades de baixa renda, em que casas são ocasionalmente invadidas sem o amparo do Direito.

Nesse sentido, aliás, caracterizou-se a intervenção do Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE n. 603.616/TO, em raciocínio paralelo ao que levou à edição da Súmula Vinculante n. 11, da qual se extrai a necessidade de documentar,

por escrito, as razões que justificaram o uso de algemas em pessoa presa. É dizer, se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa – ostentando, portanto, verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção –, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria de demandar-se, em juízo de proporcionalidade, a legitimidade de igual providência para a invasão de um domicílio, quando, a priori, tem-se apenas a suspeita da ocorrência de um crime. Ainda em tom de reflexão, identifico dois desses requisitos exigidos pela jurisprudência do Tribunal Supremo da Espanha como merecedores de maior ênfase. O primeiro deles é o mencionado na alínea d, i. e., a outorga consciente e livre da autorização para o ingresso no domicílio, que, à evidência, pressupõe ausência de violência ou qualquer intimidação ou outra circunstância periférica "por parte da polícia. Note-se que a normativa pretoriana daquele país expressamente dispõe, se o consentimento provier de pessoa já presa ou conduzida, que a anuência do preso somente será válida caso ocorra com a assistência de um advogado. Com o intuito apenas de enriquecer a reflexão sobre o tema, menciono os termos da exigência judicial, na jurisprudência espanhola, da assistência do advogado ao réu detido em tal hipótese: El consentimiento a la realización de la diligencia, uno de los supuestos que permiten la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, requiere que ha de ser prestado ante un letrado que le asista y ello porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar, indudablemente, a su derecho a la inviolabilidad y también a su derecho de defensa, a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y alcance del acto de naturaleza procesal que realiza" (STS 2-12-1998). Si la asistencia de letrado es necesaria para que éste preste declaración estando detenido, también le es necesaria para asesorarle si se encuentra en la misma situación para la prestación de dicho consentimiento, justificándose esta doctrina en que no puede considerarse plenamente libre el consentimiento así prestado en atención a lo que se ha venido denominándose "la intimidación ambiental" o "la coacción que la presencia de los agentes de la actividad representan" (STS. 831/2000 de 16.5). O segundo requisito que me parece importante sublinhar é o objeto da alínea e, supra, que regula a situação na qual diversas pessoas sejam atingidas pela violação do domicílio. Em semelhante hipótese, a jurisprudência espanhola se contenta com a autorização de uma pessoa, desde que seja cotitular do direito sob proteção. Assim, não se poderia validar o ingresso policial em uma residência se quem consentiu na entrada dos agentes da segurança pública era, por exemplo, pessoa não residente, mas apenas frequentadora do local. Atente-se para a circunstância, muito corriqueira, de que dentro de uma morada se encontram pessoas outras além do suspeito, as quais também são titulares do direito à preservação de sua intimidade e de sua dignidade, máxime quando se encontram no aconchego e na tranquilidade da noite, após uma jornada de trabalho, na companhia de crianças e de idosos, os quais, provavelmente, nenhuma responsabilidade têm na situação fática que ensejou a invasão do domicílio. (STJ - REsp: 1558004 RS 2015/0249614-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

Até que, mais recentemente, em paradigmático voto no julgamento do Habeas Corpus nº 598.051 SP, em 02.03.2021, o Ministro Rogério Schietti enfrentou com profundidade o problema, propondo como conclusão do julgado neste ponto que:

"3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo."

Tal entendimento, até então da 6ª Turma da Corte, foi acompanhado pela 5ª Turma em 30.03.2021, em julgado de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas. Segue o trecho da ementa relativo ao consentimento do morador:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). (...) (STJ - HC: 616584 RS 2020/0257456-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

No caso em tela, não há qualquer prova nos autos de que tenha havido consentimento do réu, consentimento este que foi por ele negado em juízo.

E, ainda que tivesse havido consentimento, não foi demonstrado inequivocamente que ocorreu de forma voluntária e livre, sendo manifesta a coação ambiental/circunstancial/situacional/indireta que a abordagem realizada por policiais armados causa nos indivíduos, mormente naqueles desconhecedores de seus direitos mínimos.

Como destacou o Ministro Ribeiro Dantas no voto acima citado (HC 616.584-RS), "anote-se que a situação específica dos autos também permite supor que a "dita autorização" estaria viciada pela intimidação ambiental, já que os acusados foram algemados, colocados na viatura policial e estavam na presença de policiais fardados. Nesse passo, ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree)."

Uma comparação singela entre ramos do Direito pode ser elucidativa. No Direito do Consumidor, que lida com direitos meramente patrimoniais disponíveis em uma relação entre particulares, a manifestação de vontade do consumidor, ainda que feita por escrito, muitas vezes - até com razoável facilidade e mesmo de ofício - é anulada pelo Judiciário quando lhe é prejudicial em razão da disparidade de forças e da impossibilidade concreta de negociação. Por que então no Direito Penal, que lida com direitos indisponíveis de um indivíduo em face do Estado, considerar livre e válido o suposto consentimento do morador (em geral sequer documentado), cuja consequência é a imposição de uma pena privativa de liberdade de até 15 anos de reclusão (no caso do tráfico) sem absolutamente nenhum benefício em troca?

Em outras palavras: por que alguém que guarda objetos ilícitos que podem lhe custar até 15 anos de prisão consentiria com a entrada da polícia em sua casa para realização de busca, senão pelo desconhecimento do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio ou pelo temor do que poderia resultar de sua negativa, isto é, pela falta de condições concretas de negar, ainda que não haja coação direta por parte dos agentes policiais?

Foi o que o Ministro Rogério Schietti, do STJ, asseverou no julgamento do HC 598.051-SP em 02.03.2021: "Nesse quadro, soa inverossímil a versão policial, ao narrar que o paciente teria mostrado onde residia – mesmo nada sendo encontrado em seu poder – e que teria franqueado a entrada em seu domicílio. Ora, um mínimo de vivência e bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Será mesmo que uma pessoa sobre quem recai a suspeita de traficar drogas irá franquear a entrada na residência, onde está a droga escondida? A troco de que faria isso??"

Nessa linha de raciocínio, segundo precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos, a voluntariedade do consentimento deve ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto, isto é, analisando-se fatores subjetivos (relacionados ao sujeito do consentimento) e objetivos (relacionados ao contexto do consentimento) para verificar se houve voluntariedade na declaração de vontade ou se a declaração deriva de uma situação de coação, em que predomina o temor em detrimento da autonomia da vontade.

É importante notar que a coação/constrangimento ao sujeito pode ser involuntariamente provocada pelo aparato policial em virtude de simples circunstâncias objetivas da abordagem ou da condição pessoal do sujeito abordado, não devendo ser necessariamente relacionada à má-fé, ao abuso ou à truculência policial. Ou seja, não se trata de desmerecer a valorosa e honrosa atividade policial ou de presumir a prática de coações por parte dos policiais. O que se pondera, contudo, é o medo que os cidadãos em geral possuem de contrariar as autoridades estatais por conta do desconhecimento do que é ou não lícito e ao que estão ou não obrigados, circunstância esta que influencia na validade do consentimento.

O homem médio brasileiro, profundo desconhecedor de suas garantias mínimas, sente-se coagido diante de tal interpelação policial, sendo que às vezes dá permissão para a prática de atos pelos agentes do Estado, aos quais não está obrigado a se submeter, mas o faz por receio do que pode advir de sua negativa, e não por livre e consciente manifestação de vontade.

Lembra-se aqui da figura do metus publicae potestatis, consistente em uma "situação em que o cidadão atua com reverência e temor quando está diante de uma autoridade pública". Tal temor provocado no particular pela natureza do cargo ocupado pelo agente público em determinada interação (metus publicae potestatis) é considerado pela doutrina para diferenciar, por exemplo, a tipicidade das condutas de corrupção passiva (CP, art. 317 – solicitar) e concussão (CP, art. 316 – exigir) por agentes públicos.

Demonstrando concretamente esse medo, a pesquisa ICJ Brasil aferiu em 2016 que "56% dos brasileiros concordam que se deve fazer qualquer coisa que um policial pede, mesmo quando se discorda da requisição".

Foram considerações dessa ordem, aliás, que levaram a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso *Miranda v. Arizona* 384 US 436 (1966), a exigir a advertência expressa quanto ao direito ao silêncio e à assistência por advogado pelo indivíduo preso, a fim de assegurar a voluntariedade de eventual confissão feita em delegacia, ambiente reconhecido como intimidador.

III) FUNDADAS RAZÕES CONCRETAS DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO NO LOCAL E INVIABILIDADE DE AGUARDAR UM MANDADO JUDICIAL EM RAZÃO DA URGÊNCIA DA SITUAÇÃO

III. a) Fundadas razões

A questão relativa às buscas domiciliares sem mandado foi objeto de tese de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.616, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na tese firmada ficou assentado que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de

responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

Ocorre que as interpretações para o que seriam as “fundadas razões” têm sido distintas país afora, havendo ainda quem entenda ser suficiente para o ingresso sem mandado judicial o mero fato de tratar-se de crime permanente (art. 303, CPP). Entretanto, se a interpretação da tese firmada em repercussão geral gera tantas soluções diversas, entendendo seja necessário socorrer-se à ratio decidendi do acórdão, que pode trazer maior clareza à hermenêutica judicial, embora não necessariamente leve a uma conclusão unânime nos tribunais brasileiros.

O Ministro Relator, ao iniciar seu voto aponta:

“A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal afirma sem ressalvas que as autoridades podem ingressar em domicílio, sem a autorização de seu dono, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente. Pretendo demonstrar que essa tese esvazia a inviolabilidade domiciliar, contrariando a interpretação sistemática da própria Constituição e tratados de direitos humanos dos quais o país é signatário. Por isso, proporei evolução do entendimento”. (destacou-se)

Fixada, portanto, a premissa de que a hipótese de flagrante delito em caso de crime permanente, por si só, não justifica a entrada em domicílio sem o competente mandado, o que correspondia ao entendimento antigo e superado do Supremo.

O próprio Ministro Gilmar Mendes reconhece que a solução por ele proposta ainda trará lacunas, mas que o objetivo do julgado é tornar a jurisprudência coerente com a Constituição da República e os tratados de direitos humanos e criar uma cultura judicial em que os juízes analisem, a posteriori, a existência de um lastro mínimo de razões (provas) existentes antes do ingresso que justifiquem medidas invasivas sem a existência de mandado de busca e apreensão:

“A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução fundadas razões demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário”. (destacou-se)

Entretanto, ao longo do voto, e discorrendo sobre as abusividades que devem ser evitadas ou coibidas, ainda que a posteriori, o Relator joga alguma luz sobre a problemática.

Primeiramente, sobre a forma como a questão vinha sendo tratada pelos Tribunais Superiores até o momento, o Ministro Gilmar Mendes consignou:

“Por definição, nos crimes permanentes, há um intervalo entre a consumação e o esgotamento. Nesse intervalo, o crime está em curso. Assim, se dentro do local protegido o crime permanente está ocorrendo, o perpetrador estará cometendo o delito. Caracterizada a situação de flagrante, viável o ingresso forçado no domicílio. Assim, por exemplo, no crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/06 –, estando a droga depositada em uma determinada casa, o morador está em situação de flagrante delito, sendo passível de prisão em flagrante. Um policial poderia ingressar na residência, sem autorização judicial, e realizar a prisão. Essa interpretação, a despeito de tradicional em nosso direito, é insatisfatória”. (destacou-se)

Em sua proposta de avançar na interpretação do tema, apontou que:

“Do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida. Em verdade, dificilmente a certeza estará ao alcance da polícia. Se certeza do crime e de sua autoria houvesse, a diligência seria desnecessária (...) Considerado o entendimento atual, o policial ingressará na casa sem a certeza de que a situação de flagrante delito, de fato, ocorre. Se concretizar a prisão, poderá dar seu dever por cumprido. Em caso contrário, terá, ao menos em tese, incorrido no crime de violação de domicílio, majorado pela sua qualidade de funcionário público, agindo fora dos casos legais – art. 150, §2º, do CP. Ou seja, o policial estaria assumindo o risco de perpetrar um crime, salvo se tiver sucesso em sua diligência. Isso dá ao policial um perigoso incentivo. Ou desvenda o crime, ou responde pessoal e criminalmente pela violação de domicílio”. (destacou-se)

O Ministro Gilmar Mendes pondera, assim, que qualquer alegação por parte dos policiais de que tinham informações sobre a ocorrência de um crime afastaria a

inviolabilidade domiciliar, e nos colocaria em situação de arbitrariedade, pois não se pode admitir que a constatação da situação de flagrância em momento posterior ao ingresso forçado justifique a medida. Dessa forma, obtempera:

“A proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois. O controle judicial da investigação criminal serve para compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública. Esse controle pode ser a priori – antes da adoção da medida que afeta direitos fundamentais – ou a posteriori – após a adoção da medida. No controle prévio, a adoção da medida deve ser precedida da expedição de uma ordem judicial. O juiz, terceiro imparcial, analisa a presença dos requisitos da medida e, se for o caso, autoriza sua realização. No controle a posteriori, a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito”. (destacou-se)

“Assim, voltando ao exemplo da droga mantida em depósito em residência, se o policial obtém, mediante denúncia anônima, a informação de que a droga está naquela casa, não poderá pedir mandado judicial, porque ninguém se responsabilizou validamente pela declaração – art. 5º, IV, CF. (...) Em consequência, resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. Ou seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio estava presente”. (destacou-se)

Por fim, ao tratar de quais elementos poderiam ser considerados como justa causa a afastar a garantia de inviolabilidade de domicílio, o Relator aponta:

“Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio. No entanto, ao ouvir gritos de socorro e ruídos característicos de uma briga vindos de dentro de uma residência, o policial tem fundadas razões para crer que algum crime está em andamento no ambiente doméstico. Não se deve exigir que busque confirmação adicional para agir. Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa”. (destacou-se)

Tem-se, dessa forma, que o próprio acórdão da tese de Repercussão Geral, embora afirme que os contornos concretos de sua decisão seriam delimitados com o passar do tempo, de antemão já aponta situações que não configurariam justa causa, ou, na locução da tese “fundadas razões”, como denúncias anônimas, pois é prova não passível de ser repetida e contraditada em juízo.

A leitura do voto e das discussões realizadas pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal aponta que à época do julgamento houve a preocupação de limitar o arbítrio estatal, garantindo a inviolabilidade do domicílio, principalmente das populações mais humildes e vulneráveis, mantendo a atuação policial em prol da segurança pública de forma a criar, inclusive, espaço de garantia para a força policial a fim de que ela não responda por delitos de invasão de domicílio.

Outra preocupação dos Ministros era não esgotar as hipóteses em que seria razoável o ingresso forçado em domicílio, pois os casos concretos são mais amplos do que uma tese abstrata pode fixar. Deixaram, assim, e expressamente, o campo aberto para formação de jurisprudência sobre o tema.

E nesse sentido é que a jurisprudência das duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado